Федеральная
Антимонопольная
Служба

(/)

База решений
и правовых актов

Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России

Решение №РВ-08/12334 РЕШЕНИЕ по делу №016/05/18-1352/2024 от 29 ноября 2024 г.

Вид документа	Решение (/?type=1&category=46091)
Дата регистрации	29.11.2024 (/?type=1&start_date=29.11.2024&finish_date=29.11.2024)
Управление	Татарстанское УФАС России (/?type=1&divisions=eea49087-10bb-4901-be60-f9c5aacb5aa9)
Сфера деятельности	Не указана
Дело	Дело №016/05/18-1352/2024 дело №016/05/18-1352/2024 по признакам нарушения части 1, 2 ... (/cases/a05ac9f0-0ad9-41d3-9ff3-4634c76cfb1a/)
Процедура	Реклама (/?type=0&procedure=43006)
Приложения	Отсутствуют

Текст документа

⊕ Сохранить как PDF (/generate_pdf/430049e4-6518-4a43-b17a-87a9f5630eb6/)

Исх. №РВ-08/12334 от 29.11.2024 г.

Комиссия Татарстанского УФАС России по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе в составе:

Председатель Комиссии:	<…>– [должностное лицо]
Члены Комиссии:	<…>– [должностное лицо]
	<…>– [должностное лицо]

рассмотрев материалы дела в отношении ООО «Агроторг» по факту распространения рекламы посредством направления сообщений с буквенного номера «Pyaterochka» на номер телефона <…> 03 августа 2024 года в 09 часов 03 минуты, 04 сентября 2024 года в 12 часов 20 минут, 11 сентября 2024 года в 10 часов 55 минут без предварительного согласия абонента, что имеет признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

УСТАНОВИЛ:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее – Управление, Татарстанское УФАС России) на рассмотрение поступило обращение от <…>– [физическое лицо] (вх.№8357/ж от 05.08.2024 г.) о распространении 03.08.2024 года в 09 часов 03 минут на телефонный номер заявителя +7(903)-319-90-00 без предварительного его согласия посредством телефонного сообщения с буквенного номера «Pyaterochka».

Фотоизображение представлено ниже:

<…>

В пункте 1 статьи 3 Закона «О рекламе» дано понятие рекламы — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Согласно Приказу, ФАС России от 14.11.2023 N 821/23 "Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований "Понятие рекламы" Федеральный закон "О рекламе" не распространяется на информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом. (пункт 2 части 2 статьи 2 Федерального закона "О рекламе")

Поскольку посредством сетей электросвязи может направляться не только, реклама, но и иные виды информации, необходимо учитывать следующее.

С учетом части 2 статьи 2 Федерального закона "О рекламе", а также пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" не может быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота. То обстоятельство, что информация, обязательная к размещению в силу закона или размещенная в силу обычая делового оборота, приведена не в полном объеме, само по себе не влечет признания этой информации рекламой.

Доведенная до сведения заявителя информация не относится к категории той информации, на которую Закон о рекламе не распространяет своё действия в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона о рекламе. В частности, она не является справочно-информационным и аналитическим материалом (обзором внутреннего и внешнего рынков, результатом научных исследований и испытаний), не имеющим в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой.

Вместе с тем распространяемая посредством SMS-сообщений или PUSH-уведомлений информация о дополнительных услугах, предлагаемых операторами сотовой связи абонентам, с которыми у них заключен договор на оказание услуг, может рассматриваться в качестве рекламы, если такая услуга выступает в качестве объекта рекламирования.

Согласно информации, размещенной на сайте https://5ka.ru/feedback/faq/category/141fdd86-dadc-4af8-981d-594d957ed11e Апельсин — это новый сервис лояльности, который объединил лидеров рынка самых востребованных категорий: «X5 Клуб»; сервис «Пакет»; Альфа-Банк; билайн; АльфаСтрахование.

Апельсин даёт клиентам «Пятёрочки» и «Перекрёстка» возможность совершать покупки с кешбэком более 20%. Сервис объединяет всех партнёров единой валютой лояльности — Апельсинками.

Апельсинками можно оплатить часть стоимости покупок по курсу 10 Апельсинок = 1 ₽.

Чтобы списать Апельсинки, достаточно:

предъявить карту лояльности кассиру и сказать, что хотите списать кешбэк;

на кассе самообслуживания нажать соответствующую кнопку перед оплатой покупки.

Условия зависят от того, где вы хотите оплатить:

В «Пятёрочке» Апельсинками можно оплатить до 50% стоимости покупки, но нельзя потратить больше 2000 Апельсинок за один раз.

В «Перекрёстке» — до 30% в розничных магазинах и до 50% в доставке, но не более 3000 Апельсинок за один раз.

в «Много лосося» Апельсинками можно оплатить до 50% от стоимости заказа.

во «Vprok.ru Перекрёсток» — до 30% от стоимости заказа и до 6000 Апельсинок за одно списание.

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Для признания информации рекламой необходимо ее соответствие признакам рекламы, перечисленным в пункте 1 статьи 3 Федерального закона "О рекламе".

При этом под неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта рекламирования.

Таким образом, под рекламой понимается определенная не персонифицированная информация, направленная на продвижение определенного объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному списку.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что целью направления рассматриваемого сообщения является привлечение внимания потребителей к магазинам «Х5 Клуб» путем направления им информации о получении баллов «Апельсинок», а также стимулирование потребителей для совершения покупок в магазине «Х5 Клуб».

Рассматриваемая информация, которая доводилась до сведения Заявителя посредством сообщений на номер телефона <…> 03.08.2024, является рекламой, поскольку отвечает всем квалифицирующим признакам рекламы:

- информация распространена на электронную почту по сети электросвязи, а именно посредством использования подвижной радиотелефонной связи.

Объектом рекламирования в рассматриваемом случае является как непосредственно само ООО «Агроторг», так и программа лояльности «Х5 Клуб» «Апельсинки». При этом рекламная информация направлена не на использование накопленных баллов (апельсинок), а на совершение покупок с последующим их начислением с ограниченным периодом времени, в течении которого они могут быть использованы.

Согласно информации представленной ПАО «Вымпелком (вх.№9463 от 02.09.2024) буквенный номер «Pyaterochka» принадлежит ПАО «Мегафон».

Согласно информации представленной ПАО «Мегафон» (вх. № 9976 от 17.09.2024) отправка рассматриваемого сообщения была осуществлена ПАО «Корпоративный центр Икс5» на основании заключенного с ПАО «Мегафон» договора.

В рамках вышеуказанного договора ООО «Корпоративный центр Икс5» является лицом, определяющим объект рекламирования, круг получателей рекламы и использующее для распространения рекламы, услуги, оказываемые ПАО «Мегафон».

27 сентября 2024 г. в адрес Управления поступили пояснения ПАО «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5» (вх.№10434 от 27.09.2024) исходя из которых следует, что Общество является управляющей компанией ООО «Агроторг» на основании решения от 03.07.2024 и договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации от 05 марта 2019 г. ФТС «Пятерочка» принадлежит ООО «Агроторг». В рамках своих полномочий ПАО «КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5» осуществляет функции по руководству текущей деятельности ООО «Агроторг», при этом деятельность по реализации и продвижению товаров, взаимодействию с потребителем, направлению рекламных рассылок осуществляется непосредственно ООО «Агроторг».

Управлением был отправлен запрос в адрес ООО «Агроторг». Общество представило согласие абонента на получение рекламы в следующем виде:

<….>

Также согласно пояснениям Общества текст смс рассылок и список получателей, направляемых потребителям, утверждаются сотрудником ООО «Агроторг».

16 октября 2024 г. в адрес Управления поступили пояснения ООО «Агроторг» (вх.№11121) исходя из которых следует, что в ООО «Агроторг» утверждены и действуют программы лояльности «Х5 Клуб» (далее – Программа) для участия в Программе необходимо получить Карту и зарегистрироваться в Программе в соответствии с правилами ее проведения. <….>– [физическое лицо] была получена и зарегистрирована карта 15 мая 2019 г. в 9 часов 53 минуты.

Информация из профиля пользователя <….>– [физическое лицо]

<….>

С момента регистрации в Программе «Х5 Клуб» Участник вступает во взаимоотношения с Оператором Программы, полностью и безоговорочно принимает настоящие Правила, обязуется их выполнять и имеет право на получение Привилегий в соответствии с настоящими Правилами.

В соответствии с п. 3.9. Программы, осуществив регистрацию в Программе и согласившись с Правилами (приняв Правила) в соответствии с условиями п. 3.4. настоящих Правил, Участник соглашается на получение от Оператора Уведомлений, предусмотренных настоящими Правилами. Участник может настроить получение Уведомлений в Личном кабинете.

Согласно 3.10. Программы согласие на получение от Оператора рекламы (рекламных сообщений) может быть выражено Участником в любой момент времени при регистрации или после регистрации в Программе, в т. ч. при использовании Мобильного приложения. Участник, предоставивший согласие на получение рекламы, вправе в любой момент отказаться от получения рекламных сообщений по одному, нескольким или всем каналам связи одним из следующих способов:

- в Личном кабинете Мобильного приложения;

- путем обращения на Горячую линию.

Согласия пользователей на получение смс рассылки, рекламы из личных кабинетов участников программы выгружаются в программу Hive и профиль лояльности пользователя clm5_customers.

<….>

Пояснения по информации из базы данных Hive:

- строка sms_permission _flg_tc5: true - подтверждает наличие согласия у клиента на получение

уведомлений по смс.

- строка permission_adverts_flg_tc5: true - подтверждает согласие на получение рекламы.

«Permission» - переводится, как «разрешение»

«True» – переводится, как «положительный»

Также ООО «Агроторг» представлено согласие на получение рекламы и уведомлений по смс из профиля лояльности пользователя clm5_customers:

<….>

Согласие на рассылку рекламы (cus_permission_adverts)

Коммуникация через SMS (cus_permission_sms)

Согласия участников программы на получение смс рассылки, рекламы из личных кабинетов пользователей хранятся в программе Hive и профиле лояльности пользователя clm5_customers.

Также на заседании Комиссии 31 октября 2024 г. <….>– [физическое лицо] было пояснено, что регистрацию в программе ООО «Агроторг», а также ввод персональных данных не производил, что подтверждаются видеозаписью, приобщенной к материалам дела.

13 ноября 2024 г. в адрес Управления поступили письменные пояснения ООО «Агроторг» (вх.№12307) исходя из которых следует, что на сегодняшний день отсутствует техническая возможность предоставления сведений о верификации пользователя <….>– [физическое лицо] 15 мая 2019 г. в связи с длительным промежутком времени с указанной даты.

Согласие на получение рекламных материалов предоставляется пользователями при регистрации в программе лояльности «Х5 клуб». Для регистрации в программе лояльности согласие на получение рекламных сообщений не является обязательным. Участник может выразить согласие путем проставления «галочки» в соответствующем чек-боксе на сайте программы либо в мобильном приложении, при обращении в Колл-Центр.

По умолчанию данный чек-бокс является пустым и не содержит предустановленной «галочки».

Регистрация в программе лояльности осуществляется одним из трех способов

- На сайте программы.

- В мобильном приложении.

- По телефону контакт-центра либо посредством СМС-сообщения по номеру 7775.

На текущий период ООО «Агроторг» не может представить информации каким способом заявитель выразил согласие на получение рекламных материалов, т.к. после регистрации личный кабинет гостя становится доступен как через сайт, так и через мобильное приложение независимо от способа регистрации.

08 ноября 2024 г. в адрес Управления поступил видеоматериал <….>– [физическое лицо] из содержания которого следует, что <….>– [физическое лицо] регистрацию на сайте и /или в приложении не производил, персональные данные <….>– [физическое лицо] в приложении ООО «Агроторг» отсутствуют.

Фотоизображение представлено ниже:

<….>

Также с буквенного номера «Pyaterochka» на номер телефона Заявителя <….> поступили сообщения с аналогичным (схожим) содержанием 04 сентября 2024 г. и 11 сентября 2024 г.

Фотоизображение представлено ниже:

<….>

Выслушав пояснения сторон и исследовав материалы дела Комиссия приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 18 Закона «О рекламе», распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» предусмотрено, что на территории Российской Федерации услуги связи оказываются операторами связи пользователям услугами связи на основании договора об оказании услуг связи, заключаемого в соответствии с гражданским законодательством и правилами оказания услуг связи

Согласно п. 35 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее - Закон о связи) под электросвязью понимаются любые излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам;работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот), средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама (подп. 2-3 ст. 3 Закона о рекламе).

Согласно пункту 1 статьи 44.1 Закона № 126-ФЗ рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи должна осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки. Рассылка признается осуществленной без предварительного согласия абонента, если заказчик рассылки в случае осуществления рассылки по его инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи в случае осуществления рассылки по инициативе оператора подвижной радиотелефонной связи не докажет, что такое согласие было получено.

В пункте 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» разъяснено, что под абонентом или адресатом надлежит понимать лицо, на чей адрес электронной почты или телефон поступило соответствующее рекламное сообщение. Поскольку Закон
№ 38-ФЗ не определяет порядок и форму получения предварительного согласия абонента на получение рекламы по сетям электросвязи, согласие абонента

может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя. Вместе с тем согласие абонента на получение от конкретного лица информации справочного характера, например, о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть истолковано как согласие на получение от этого лица рекламы.

Для признания надлежащим факта получения рекламораспространителем согласия абонента либо адресата на получение им рекламной информации изначально должно быть явно выраженное желание абонента, либо адресата на все получение, в том числе, посредством отметки соответствующего надлежащим образом оформленного пункта.

Согласие, полученное посредством заполнения каких-либо форм на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не позволяющих однозначно установить, кто именно дал согласие на получение рекламы, является ненадлежащим и влечет нарушение указанного требования ст.18 Федерального закона «О рекламе», поскольку не позволяет подтвердить волеизъявление конкретного абонента на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

В качестве доказательств получения от заявителя согласия на получение рассылки Общество представило скриншот.

Скриншот является печатной формой (текст, набор символов), из которых невозможно однозначно установить, факт совершения определенного действия, в частности факт оформления соответствующей заявки при котором предоставлено согласие на получение рекламной информации.

Также невозможно установить, кем в действительности была зарегистрирован личный кабинет физического лица и оформлена заявка.

Обществом не представлены доказательства, свидетельствующие о принятии мер к верификации заявителя (в том числе, путем получения и подтверждения <….>– [физическое лицо] смс-кода на указанный в анкете номер телефона либо иным способом).

Таким образом, в материалы дела не представлено необходимых доказательств наличия согласия абонента на получение рекламы посредством рекламных звонков. Напротив, Заявителем последовательно представлены Комиссии доказательства того, что принадлежащий ему номер телефона отсутствует в программе лояльности ООО «Агроторг» с надлежащей идентификацией.

В представленных ООО «Агроторг» материалах отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии действий заявителя либо иных лиц, связанных с оформлением заявки (техническая информация сайта) и его идентификации (верификации). Скриншот не является надлежащим и достаточным для вывода о совершенных действиях по регистрации в программе. Указанный документ, в отсутствие доказательств, подтверждающих действие заявителя (либо иных третьих лиц) по оформлению заявки от имени заявителя, являются односторонне составленным документами, которые, при условии отрицания второй стороной участия при оформлении (составлении) таких документов, подлежат критической оценке. Со стороны заявителя в ходе заседания Комиссии продемонстрирована пластиковая карта лояльности, которая ранее им была получена непосредственно в торговом объекте ООО «Агроторг»

Согласно части 7 статьи 38 Закона «О рекламе» ответственность за нарушения части 1 статьи 18 несёт рекламораспространитель.

Рекламораспространителем является ООО «Агроторг».

Материалов свидетельствующих о прекращении ООО «Агроторг» нарушения Закона о рекламе не представлено. На основании изложенного, Комиссия считает необходимым выдать ООО «Агроторг» обязательное для исполнения предписание.

Ввиду изложенного и на основании пункта 2 части 1 статьи 33, частей 1, 2 статьи 36 Федерального закона «О рекламе», а также в соответствии с пунктами 19, 20 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе,

РЕШИЛ:

1. Признать ненадлежащей, рекламу, распространённую ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086) посредством направления сообщений с буквенного номера «Pyaterochka» на номер телефона <….> 03 августа 2024 года в 09 часов 03 минуты, 04 сентября 2024 года в 12 часов 20 минут, 11 сентября 2024 года в 10 часов 55 минут, поскольку в ней нарушены требования части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

2. Рекламодателем и рекламораспространителем признать ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086).

3. Выдать ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086) обязательное для исполнения предписание.

4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о привлечение лица к административной ответственности.

Решение изготовлено в полном объеме 28 ноября 2024 г. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии:	<….>– [должностное лицо]
Члены Комиссии:	<….>– [должностное лицо]
	<….>– [должностное лицо]

Связанные организации

Связанные организации не указаны